جمهورية كينيا الديمقراطية

جامعة مستقبل

كلية الشريعة والقانون

قسم الفقه وأصوله

النكاح حقيقته أركانه وشروطه

(دراسة فقهية مقارنة)

البحث التكميلي لاستكمال الوحدات المطلوبة لنيل درجة البكالوريوس

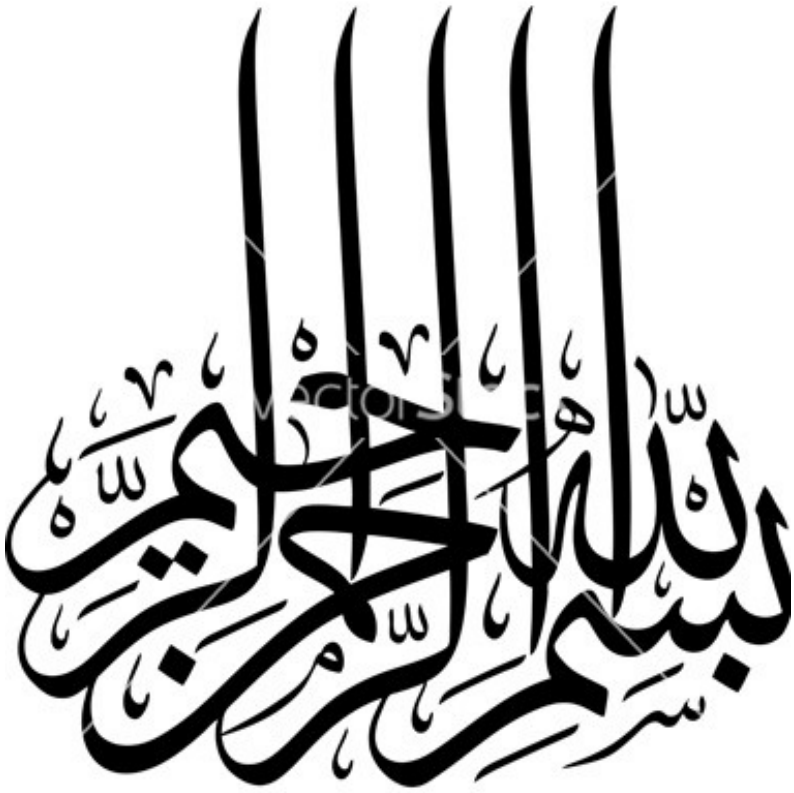
إعداد الطالب:

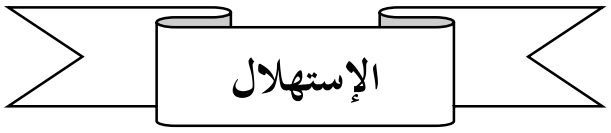
عبد العزيز محمد عبدالقادر

إشرف:

أ:ذهب قاسم حسين

رقم الجامعي:٣٧/٣٧٣ العام:١٤٤١ هـ الموافق: ٢٠٢٠م


بسم الله الرحمن الرحيم



قال الله تعالى ﴿وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾[1]

١- سورة النور (آية: ٣٢)

الإهداء

يسرني أن أكتب هذا البحث وأهديه إلى أحب الناس إليّ بعد خير البرية المصطفى محمد بن عبد الله عليه السلام، وأرجو أن ينفعني الله به في مستقبل أمري في الدنيا والآخرة، وأن يجزيه عني خير الجزاء.

إلى أمي التي ربتني بتربية الإسلام وألبستني ثوب المودة والأمان، عفر الله ذنوبها، وأدخلها بجنته (الفردوس الأعلى) رب اجعلها سيدة من سيدات الجنة.

عليها من الرحمن أعظم رحمة *** نبل ثراها بالضحى والأصائل.

إلى من حمل أمانة الأبوة، فأداها على أحسن وجه، وقام من أجل إسعادي، فأسعدني برفع المقام إلى والدي(الشيخ محمد عبدالقادر)، مني سلام على من لست أنساه – ولايمل لساني قط ذكرا.

إلى كلّ من علمنى حرفا في هذه الحياة وساعدني في الوصول إلى هذا المستوى.

وأرجوا أن يجعل الله هذا البحث صدقة جارية لي ولوالدي والله ولي ذلك والقادر عليه.

الشكر والتقدير.

لكل مبدع إنجاز، ولكل شكر قصيدة ، ولكل مقام مقال، ولكل نجاح شكر وتقدير .

أحمد الله أشكره سبحانه وتعالى فله الحمد والثناء على ما منّ به علينا من النعم التي لا تعد ولاتحصى وأجلها نعمة الإسلام والأمن والأمان والتي قل ما توجد في بلد من البلدان، كما أشكره بأن وفقني كتابة هذا البحث، وجعلني من طلاب العلم، وأسأله المزيد من فضله والعون على شكره، لأنه سبحانه وعد من شكره بالزيادة **﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾**.[1]

وأشكر أيضا والديّ اللذين رباني في العلم وطلبه وكانا عوناً وسندا لي بعد الله سبحانه وتعالى. غفر الله ذنوبهما وحفظهما وسلّمهما من سوء الدارين ورب ارحمهما كما رباني صغيرا .

ولا يفوتني في هذا المقام أن أتوجه بالشكر لمشايخي وأساتذتي وزملائي وأصدقائي الكرام وعلى كل من دلني أو اعطاني مرجعا ، وأسأل الله أن يحفظهم، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل إنه سميع قريب مجيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

١- سورة إبراهيم (الآيه ٧)

يتكون هذا البحث إلى مقدمة وثلاثة فصول:

١. سبب اختيار الموضوع

٢. مشكلة البحث

٣. اهمية الموضوع

٤. حدود البحث

٥. منهج البحث

٦. الدراسات السابقة للبحث

خطة البحث

الفصل الأول: مفهوم النكاح وحقيقته ومشروعيته وفيه ثلاثة مباحث:

- ✓ المبحث الأول:مفهوم النكاح
- ✓ المبحث الثاني: حقيقة النكاح
- ✓ المبحث االثالث: أدلة مشروعية النكاح وحكمته وفيه مطلبان
  - ➢ المطلب الأول: أدلة مشروعية النكاح
  - ➢ المطلب الثاني: حكمة مشروعيته

الفصل الثاني: حكم النكاح وأركانه وشروطه وفيه ثلاثة مباحث:

- ✓ المبحث الأول: حكم النكاح
- ✓ المبحث الثاني: أركان النكاح وفيه مطلبان.
  - ➢ المطلب الأول: تعريف الركن لغة واصطلاحا.
  - ➢ المطلب الثاني: أركان النكاح عند المذاهب الأربعة.
- ✓ المبحث الثالث: شروط النكاح وفيه أربعة مطالب:
  - ➢ المطلب الأول: شروط إنعقاد الزواج
  - ➢ المطلب الثاني: شروط صحة الزواج
  - ➢ المطلب الثالث: شروط النفاذ
  - ➢ المطلب الرابع: شروط اللزوم

الفصل الثالث: خاتمة البحث

- ➢ نتائج البحث
- ➢ توصيات البحث
- ➢ الفهارس

مقدمة البحث

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.﴿ يَا أَيهَا الذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتنَّ إِلا وَأَنْتمْ مُسْلِمُونَ﴾[1] .أما بعد

فقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على النكاح ورغب فيه، وفعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه رضوان الله عليهم اقتداء به صلى الله عليه وسلم من بعده. فكان ذلك من سنته وسنة الأنبياء الذين قبله عليهم الصلاة والسلام، يقول الله تعالى في محكم الترتيله ﴿**وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً**﴾[2] ومعنى الآية الترغيب في النكاح والحث عليه، فهو سنة المرسلين كما نصت عليه الآية، وقد جاء في السنة ما يدل على ذلك، عن أبي أيوب قَال: قَال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أربع من سنن المرسلين: الحياء والتعطر والسواك والنكاح". والنكاح عند الفقهاء هو عقد التزويج على اختلاف فيما بينهم هل يطلق عليه حقيقة أو مجازاً. ولقد أحببت أن أخوض بحثا أقف من خلاله بيان حقيقة النكاح وركانه وشروطه والله الهادي إلى سواء الصراط.

١- سورة آل عمران (آية: ١٠٢)

٢- سورة الرعد (آية: ٣٨)

سبب اختيار الموضوع:

هناك عدة أسباب اختارها الباحث على هذا الموضوع منها:

١- حاجة الناس إلى معرفة هذا الموضوع.

٢- كثرة الزواج في المجتمع.

٣- إستكمال وحدات المطلوبة في التخرج من المرحلة الجامعية.

مشكلة البحث:

إن الناظر في كتب الفقه الإسلامي يجد أن هناك كمًّا هائلًا من النكاح التي ينقلها العلماء في المذاهب الفقهية المختلفة، ومن المعلوم أن حقيقة النكاح وشروطه فرع من الفقه ويرتبط به إرتباطا وثيقا وله أهميته للبشر وخاصة للمجتمع الإسلامي. من مشكلات البحث قلة تعرض العلماء قديما وحديثا لهذ البحث "النكاح حقيقته أركانه وشروطه " بشكل تفصيلي وإفراده في مصنفات خاصة بحيث يستطيع أي باحث الرجوع إليها والإستفادة منها.وجهل كثير من الناس عن أحكام النكاح.

اهمية الموضوع:

الزَّواج سنةٌ من سُنن الأنبياء والمرسلين وهو سبيل المؤمنين، قال الله تعالى: ﴿**وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ**﴾[١] ففي هذه الآية

١- سورة النور (آية: ٣٢)

أمرٌ من الله لأوليائه بإنكاح من تحت ولايتهم من الأيامى- الأيِّم هم من لا أزواج لهم- أيّ على الرَّجل أنْ يزوّج من تحت ولايته من النِّساء والرِّجال طلبًا للعفّة والصِّيانة من الفاحشة. فالزَّواج تاجّ الفضيلة؛ لذلك أنكر النّبي صلى الله عليه وسلم على من امتنع عن الزَّواج لأيّ سببٍ كان، حتى لو كان هذا السبب قيام الليل وصِيام النَّهار؛ لذلك استّحب علماء المسلمين للمتزوج أنْ ينوي بزواجه موافقة السُّنة النّبويّة، واتباع أمر الله بإعمار الأرض والتّكاثر والتّناسل، وصيانة الدِّين والعرض. وله أهمية عظيمة منها:

١- عفة النفس والبعد بها عن إغواءات الشيطان.

٢- امتثال أمر النبي ﷺ فقد أمر للشباب القادرين على تحمل أعباء الزواج وتكاليفه أن يبادروا إلى الزواج.

٣- استمرار الذرية الحسنة، والحفاظ على بقاء النسل، ونيل الأجر بسبب الولد الصالح.

حدود البحث:

تنحصر حدود هذا البحث في النكاح حقيقة، أركانه وشروطه (دراسة فقهية مقارنة)

الدراسات السابقة للبحث:

١- فتح القدير لكمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام (المتوفى: ٨٦١هـ) ويختلف بحثي عن هذا الكتاب أنه لم يتناول عن شروط النكاح

٢- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (المطبوع مع المقنع والشرح الكبير) لعلاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرْداوي (المتوفى: ٨٨٥ هـ) تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي - الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو

الفصل الأول

مفهوم النكاح وحقيقته ومشروعيته وفيه ثلاثة مباحث

المبحث الأول: مفهوم النكاح

المبحث الثاني: حقيقة النكاح

المبحث االثالث: أدلة مشروعية النكاح وحكمته وفيه مطلبان:

- المطلب الأول: أدلة مشروعية النكاح
- المطلب الثاني: حكمة مشروعيته

المبحث الأول: مفهوم النكاح

تعريف النكاح لغة

النكاح: لغة الوطء، وقد يطلق على العقد- تقول: نكحَ فلَان امّرأة يَنكِحُها نِكاحاً إذا تزوَّجَها. وامرأة ناكح يقصد بها ذات زوج، وقيل للتزوج نكاح لأنه سبب الوطء المباح.. نكحَ فلَان امّرأة يَنكِحُها نِكاحاً إذا تزوَّجَها[1]

وقال محمد عبد القادر بن محمد بن المختار[2] في الجواهر الكنزية لنظم ما جمع في العزية

أما النكاح لغة فهو دخول *** شيء في شيء كالفروع والأصول

كنكح الحصاة أخفاف الإبل *** وقولهم قد نكح النوم المقل

قال ابن فارس: النون، والكاف، والحاء؛ أصل واحد، وهو البضاع[3]، ونَكَح ينكِح "بكسر الكاف". وامرأة ناكح في بني فلان، أي ذات زوج منهم.

ويدل النكاح أيضًا على الضم والتداخل، وهو مأخوذ من نَكَحَه الدواء: إذا خامره وغلبه، أو من تناكح الأشجار: إذا انضم بعضها إلى بعض[4].

١- أنظر: تهذيب اللغة محمد بن أحمد بن الأزهري د/ إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة: الأولى (ص٦٤/ ٤)

٢ – أبو عبد الله محمد عبد القادر بن محمد بن المختار بن أحمد العالم القبلوي الجوائي المالكي الشهير بالشيخ باي بلعالم (المتوفى: ١٤٣٠ هـ)

٣- البضاع: هو الجماع، يقال: ملك فلان بُضع فلانة إذا ملك عقدة نكاحها، وهو كناية عن موضع الغشيان، والمباضعة: المباشرة. انظر: "لسان العرب" (٨/ ١٤).

٤- أنظر: "المصباح المنير لأحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس (المتوفى: نحو ٧٧٠هـ) د: المكتبة العلمية – بيروت عدد الأجزاء:٢ بدون طبعة. (٢/ ٢٩٥ – ٢٩٦)

يقال: نكحتَ البُر في الأرض إذا حرثتها وبذرته فيها، ونكحَتْ الحصى أخفاف الإبل: إذا دخلت فيها، ونكح المطر الأرض: إذا خالط ترابها، ونكح النعاس عينه: إذا غلب عليها[1]

ومن أمثال العرب: أنكحنا الفرى فسنرى، أي جمعنا بين حمار الوحشي الذكور والإناث فننظر ما يتولد منها فضرب مثلا لقوم يجتمعون على الأمر لا يدرون ما يصدر عنه. وحكى المبرد من البصريين عن الكوفيين أن النكاح عبارة عن الجمع والضم، ويستعمل في الوطء لوجود الضم ويستعمل في العقد مجازا. قال الله تعالى: **{فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ}**[2]

١- أنظر: "لسان العرب محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: ٧١١هـ) د: دار صادر – بيروت ط: الثالثة عدد الأجزاء: ١٥ (٢/ ٦٢٥ - ٦٢٦) ، و"تهذيب اللغة" (٤/ ١٠٢)

٢- سورة النساء [آية ٢٥]

تعريف النكاح إصطلاحا.

١- وصطلاحا (عقد التزويج) أي عقد يعتبر فيه لفظ نكاح أو تزويج أو ترجمته وهو حقيقة في العقد، مجاز في الوطء[١]

٢- عرّفه ابن الهمام من الحنفية بأنه: عقد وضع لتملك المتعة بالأنثى قصدًا[٢].

وقد يعترض على هذا التعريف بأن الاستمتاع يقع من جهة الزوجة أيضًا، مع أنه لا ملك لها.

٣- وعرّفه الدردير[٣] من المالكية بأنه: عقد لحل تمتع بأنثى، غير محرم ومجوسية وأمة كتابية، بصيغة، لقادر محتاج، أو راجٍ نسلا[٤].

وقد يعترض على هذا التعريف أيضًا بما اعترض على سابقه، وأن النكاح مندوب إليه لصيانة النفس وإعفافها، ولو لم يحصل الولد.

٤- وعرّفه زكريا الأنصاري[٥] من الشافعية بأنه: عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح، أو نحوه[٦].

ويعترض على هذا التعريف بأن العقد يباح به ما هو أعم من الوطء، فلو عبر بالاستمتاع لكان أولى؛ لدخول الوطء ومقدماته في الاستمتاع.

١- أنظر: كشاف القناع (ج٥/ص٥)

٢- أنظر: فتح القدير ٣ ص١٨٥ و"التعريفات" للجرجاني ص ٣١٥.

٣- هو أحمد بن محمد العدوي، الشهير بالدردير، من فقهاء المالكية، ولد سنة (١١٢٧ هـ)، وتعلم بالأزهر، ألف في المذهب؛ مثل: "أقرب المسالك لمذهب مالك"، وتوفي بالقاهرة سنة (١٢٠١ هـ). انظر في ترجمته: "شجرة النور الزكية" ١ص٥١٦.

٤- أنظر: بلغة السالك ج٢ ص٢١٢.

٥- هو أبو يحيى شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري، جدّ في طلب العلم؛ فأخذ عن جماعة من أشهر علماء عصره، ولي القضاء بعد امتناع، وصنف التصانيف النافعة؛ منها: "فتح الوهاب"، عُمِّر طويلا، توفي سنة (٩٢٥ هـ). انظر في ترجمته: شذرات الذهب م٨ ص١٣٤

٦- فتح الوهاب ج٢ ص٣٩.

٥- وعرّفه المرداوي من الحنابلة بأنه: عقد التزويج، فهو حقيقة في العقد، مجاز في الوطء[١].

ويعترض على هذا التعريف بأن فيه دورًا؛ فقد عرّف الشيء بنفسه، وهذا عيب في التعريف.

وسُمي بذلك لأنه يجمع بين شخصين، ويضمّ أحدهما إلى الآخر.

وبعد عرض تعريفات الفقهاء للنكاح، والنظر فيما يمكن أن يؤخذ على كل منها، يمكن الخروج بتعريف يشمل ما ذكر في التعريفين الأخيرين: (**عقد شرعي يحل به استمتاع كل من الزوجين بالآخر**).

شرح التعريف: "عقد": جنس في التعريف يشمل عقد النكاح وغيره، وينصرف إلى النكاح باعتبار ما سيأتي من ألفاظ في بقية التعريف، ويشمل عقد النكاح ألفاظ التزويج المعتبرة عند أهل العلم، والمذكورة في تعريف الشافعية.

"شرعي": قيد في التعريف يخرج به كل عقد غير معتبر شرعًا، كنكاح المتعة مثلًا، أو ما يفعله بعض الجهّال من كتابة ورقة بين الرجل والمرأة واعتبارها عقدًا شرعيًا، ويسمونه نكاحًا عرفيًّا.

"يحل به": قيد يخرج به كل عقد لا يحل به النكاح، وهذا يعني أيضًا أنه بهذا العقد أصبح النكاح مباحًا بعد أن كان محظورًا، إذن "الأصل في الأبضاع التحريم"[٢].

"استمتاع": كلمة في التعريف أشمل من كلمة الوطء الواردة في التعريفات السابقة، لأن الاستمتاع يشمل الوطء ومقدماته.

١- أنظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ج٨ ص٤.

٢- أنظر: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص ٦١) ، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص/٥٧.

"كل من الزوجين بالآخر": قيد يخرج به كل استمتاع بين رجل وامرأة ليسا بزوجين. ويخرج به أيضًا كل استمتاع يقع بين الرجل وجاريته؛ فإنها لا تسمى زوجة، ولا يحصل بوطئها إحصان.

قال ابن قدامة: ولا خلاف بين أهل العلم في أن الزنى، ووطء الشبهة، لا يصير به الواطئ محصنًا، ولا نعلم خلافًا في أن التسري لا يحصل به الإحصان لواحد منهما؛ لكونه ليس بنكاح، ولا تثبت فيه أحكامه[1]

والعرب تستعمل لفظ النكاح بمعنى العقد، وبمعنى الوطء والاستمتاع. وعامة استعمال القرآن للفظ النكاح إنما هو في العقد، لا في الوطء. ومنه قوله تعالى: {**يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا** .. }[2]

ومعنى {نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} عقدتم عليهن. بدليل قوله: {**ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ**} فمعناه: طلقتموهن قبل المسيس وهو الوطء والدخول.

١- انظر: المغني ج١٢ ص٣١٥.

٢- سورةالأحزاب (آية:٤٩)

المبحث الثاني: حقيقة النكاح

حقيقة النكاح في اللغة

وقع خلاف بين أهل اللغة في لفظ النكاح بين الحقيقة والمجاز، ويمكن حصر خلافهم في أربعة الأقوال:

القول الأول: إنه حقيقة في العقد، مجاز في الوطء.

ويدل عليه ما ذكره ابن فارس؛ حيث قال: "والنكاح يكون العقد دون الوطء"[١]

القول الثاني: إنه حقيقة في الوطء، مجاز في العقد.

ويدل عبارة الجوهري[٢]؛ حيث قال: النَّكاح: الوطء، وقد يكون العقد[٣].

وكأنه بهذا يشير إلى قلة استعماله في العقد.

القول الثالث: إنه لفظ مشترك يأتي بمعنى العقد، ويأتي بمعنى الوطء، ولا يفهم المراد منه إلا بقرينة؛ فإذا قالوا: نكح فلان بنت فلان: أي عقد عليها، وإذا قالوا: نكح زوجته: لم يريدوا إلا الوطء[٤].

ومن هنا جاء في عبارات الفقهاء: وليس للمحرم نكاح زوجته، أي: وطئها.

ويدل على هذا القول ما ذكره الفيروز أبادي [٥]؛ حيث قال: "النكاح: الوطء، والعقد له"[٦].

١- معجم مقاييس اللغة (ج٥/ ٤٧٥).

٢- هو أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، مات سنة (٣٨٦ هـ). انظر في ترجمته: "معجم الأدباء" (ج٢/ ٢٠٥).

٣- الصحاح (ج١/ ٦٠٨).

٤- تاج العروس" (ج٧/ ١٩٦)، و"المصباح المنير" (ج٢/ ٢٩٦).

٥- هو مجد الدين أبو الطاهر محمد بن يعقوب الفيروز أبادي اللغوي المشهور، شافعي المذهب، دخل شيراز والعراق والشام ومصر فأخذ عن علماء كل بلد، وظهرت فضائله، روى الكتب الستة، و"مسند أحمد"، وغيرها، من أشهر مصنفاته: "القاموس المحيط"، توفي في زبيد سنة (٨١٧ هـ) انظر في ترجمته: "شذرات الذهب" (ج٧/ ١٢٦)، "البدر الطالع" (ج٢/ ١٤٩).

٦- القاموس المحيط" (ص ٣١٤).

وقال الفيومي[1]: "وعلى هذا فيكون النَّكاح مجازًا في الوطء والعقد جميعًا؛ لأنه مأخوذ من غيره، فلا يستقيم القول بأنه حقيقة لا فيهما ولا في أحدهما، ويؤيده أنه لا يفهم العقد إلا بقرينة نحو: نكح في بني فلان، ولا يفهم الوطء إلا بقرينة نحو: نكح زوجته، وذلك من علامات المجاز؛ لأنه لا يفهم واحد من قسميه إلا بقرينة"[2]. واستدل بعض الفقهاء على هذا القول

القول الرابع: إنه حقيقة في الجمع والضم والتداخل.

قال أبو عمر[3] غلام ثعلب: الذي حصّلناه عن ثعلب[4] عن الكوفيين، عن البصريين أنه الجمع.

ونقل المرداوي عن الشيخ تقي الدين ابن تيمية قوله: "معناه في اللغة الجمع والضم على أتم الوجوه، فإن كان اجتماعًا بالأبدان فهو الإيلاج الذي ليس بعده غاية في اجتماع البدنين، وإن كان اجتماعًا بالعقود، فهو الجمع بينهما على الدوام واللزوم، ولهذا يقال: استنكحه المذي إذا لازمه وداومه"[5].

١- هو أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي، ولد ونشأ بالفيوم في مصر، ورحل إلى حماة في سوريا، وكان خطيبًا في جامع الدهشة الذي بناه الملك المؤيد إسماعيل، اشتهر بكتابه "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير" للرافعي، توفي سنة (٧٠٧ هـ). انظر في ترجمته: "الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة" (م١/ ٣١٤).

٢- تاج العروس" (ج٧/ ١٩٦).

٣- هو أبو عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد، من أكابر أهل اللغة وأحفظهم لها، كان ثقة صدوقًا عند أهل الحديث، من مصنفاته: "الياقوتة في اللغة"، "غريب الحديث"؛ توفي سنة (٣٤٥ هـ) في بغداد. انظر في ترجمته: "معجم الأدباء" (ج٥/ ٣٦٩).

٤- هو أبو العباس ثعلب أحمد بن يحيى الشيباني، كان إمام الكوفيين في زمانه في النحو واللغة،توفي سنة (٢٩١ هـ) في بغداد. انظر في ترجمته: معجم الأدباء (ج٢/ ٥٥).

٥- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ج٨/ ٣).

حقيقة النكاح عند الفقهاء

وأيضًا قع الخلاف بين الفقهاء ، في لفظ النكاح، هل يحمل على الحقيقة أو على المجاز؟ ولعل سبب اختلاف الفقهاء مبني على الخلاف عند أهل اللغة، ويمكن حصر أقوال الفقهاء فيما يأتي:

القول الأول: إنه حقيقة في العقد، مجاز في الوطء. وهو قول الجمهور

أدلتهم: أولًا: أن لفظ النكاح بمعنى عقد التزويج هو المشهور الذي جاءت به الآيات والأخبار عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم–؛ فمن ذلك:

١– قوله تعالى: **﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾**[١] الخطاب هنا للأولياء بأن يزوجوا من لا زوج له؛ فإنه طريق للتعفف[٢]. وعلى هذا فالنكاح هنا بمعنى التزويج.

٢– قوله –صلى الله عليه وسلم–: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له"[٣]

قال أصحاب هذا القول: الوطء إنما يجوز بالعقد، وليس بالإذن المجرد عنه، بل قالوا: إنه لم يرد لفظ النكاح في القرآن إلا بمعنى التزويج[٤].

١– سورة النور: (آية٣٢)

٢– الجامع لأحكام القرآن (ج١٢/ ص٢٢١).

٣– أخرجه أبو داود (٢٠٨٣) (ج٢/ ٢٢٩) ، والترمذي (١١٠٤) (ج٢/ ٣٥٢) ، وابن ماجه (١٨٧٩) (ج١/ ٥٩٠) ، كلهم عن عائشة –رضي الله عنها–. قال الترمذي: هذا حديث حسن. قال ابن حجر: تكلم فيه بعضهم من جهة أن ابن جريج قال: لقيت الزهري، فسألته عنه؛ فأنكره، فضُعِّف هذا الحديث من أجل هذا. لكن ذكر عن يحيى بن معين أنه قال: لم يذكر هذا عن ابن جريج إلا ابن علية، ورواية ابن علية عن ابن جريج ضعيفة. وأعل الحكاية عن ابن جريج: ابن حبان، وابن عدي، وابن عبد البر، والحاكم، وغيرهم، وأجابوا على تقدير الصحة بأنه لا يلزم من نسيان الزهري لهذا الحديث أن يكون سليمان بن موسى – الراوي عن الزهري – وَهِمَ فيه. انظر: "التلخيص الحبير" (٣/ ١٥٦ – ١٥٧).

٤– المغني (ج٩/ ص٣٣٩) ، فتح الباري (ج٩/ ص١٠٣) ، وكشاف القناع (ج٥/ ص٥).

وقال الراغب الأصفهاني[1]: "أصل النكاح للعقد، ثم استعير للجماع، ومحال أن يكون في الأصل للجماع ثم استعير للعقد؛ لأن أسماء الجماع كلها كنايات؛ لاستقباحهم ذكره كاستقباحهم تعاطيه، ومحال أن يستعير من لا يقصد فحشًا اسم ما يستفظعونه لما يستحسنونه"[2].

ثانيًا: أنه يصح نفي النكاح عن الوطء، فيقال في الزنى سفاح لا نكاح، وصحة النفي دليل المجاز[3].

ثالثًا: أن الذهن لا ينصرف إلا إليه عند الإطلاق، فاشتهر استعمال لفظ النكاح بإزاء العقد في الكتاب والسنة ولسان أهل العرف[4].

رابعًا: أن النكاح أحد اللفظين اللذين ينعقد بهما عقد النكاح، فكان حقيقة فيه، كاللفظ الآخر[5] قالوا: ولا ينتقض بما ورد في قوله تعالى: **﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾**[6] فإن معناه حتى تتزوج أي: يعقد عليها[7]. وقد ثبت مفهوم الوطء في هذه الآية عن طرق السنة في قوله -صلى الله عليه وسلم-: "حتى تذوقي عسيلته"[8].

١- هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني، المعروف بالراغب، انتقل إلى بغداد وسكنها، وكان معاصرًا للإمام الغزالي، ويقارن به، صنف عدة من المصنفات؛ منها: "المفردات في غريب القرآن" وغير ذلك، توفي سنة (٥٠٢ هـ). انظر في ترجمته: "روضات الجنات" (ص ٢٤٩).

٢- المفردات في غريب القرآن (ص ٨٢٣).

٣- المغني (ج٩/ ص٣٣٩) ، والمبدع (ج٦/ ص٨١) ، ومغني المحتاج (ج٤/ ص٢٠١).

٤- كشاف القناع (ج٥/ ٥).

٥- المغني (ج٩/ ص٣٤٩).

٦- سورة البقرة:(آية ٢٣٠)

٧- نيل الأوطار (ج٦/ ص٢١١) وشرح الزرقاني على الموطأ (ج٣/ ص١٢٤)

٨- عن عائشة -رضي الله عنها-: أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني فبتّ طلاقي، وإني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، وإن ما معه مثل الهدبة. قال رسول الله -ص لى الله عليه وسلم-: "لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك. وتذوقي عسيلته". هذا لفظ البخاري. أخرجه البخاري (٥٢٦٠) (ج٦/ ص٢٠٢)، ومسلم (رقم الحديث ١٤٣٣) "شرح النووي" (ج١٠/ص ٣).

القول الثاني: إنه حقيقة في الوطء، مجاز في العقد. وهو مذهب الحنفية[1]، وبه قال القرافي من المالكية[2]، ووجه عند الشافعية[3]، وقال به أبو الخطاب، وأبو يعلى الصغير[4] من الحنابلة[5].

• أدلة هذا القول: أولًا: أن الوطء هو الأصل في استعمال لفظ النكاح لغة -كما صرّح بذلك الأزهري وغيره- والأصل عدم النقل[6].

ثانيًا: جاء القرآن والسنة بلفظ النكاح، ويراد به الوطء[7] ، فمن ذلك:

١- قوله تعالى: **﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾**[8]

٢- قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ولدت من نكاح لا من سفاح"[9]. قال ابن الهمام: يصح حمل النكاح. في هذا الحديث على العقد، وإن كانت الولادة بالذات من الوطء .

١- المبسوط (ج٤/ ص١٩٢) ، وفتح القدير (ج٣/ ص١٨٥) ، والبحر الرائق (ج٣/ ص٨٢).

٢- الفروق (ج٣/ ص٢٠٥).

٣- شرح مسلم للنووي (ج٩/ ص١٤٥) ، ومغني المحتاج (ج٤/ ص٢٠٩).

٤- هو عماد الدين أبو يعلى الصغير محمد بن محمد بن محمد بن الحسين، ابن القاضي أبي خازم، ابن القاضي الكبير أبي يعلى، شيخ المذهب في وقته، برع في المذهب والخلاف والمناظرة، وأفتى، ودرس، وكان ذو ذكاء مفرط، وفصاحة، وحسن عبارة، توفي سنة (٥٦٠ هـ). انظر في ترجمته: "ذيل طبقات الحنابلة" (ج١/ ص٢٤٤).

٥- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ج٨/ ص٤) ، والمبدع" (٦/ ٨١).

٦- فتح القدير (ج٣/ ص١٨٥) ، والمبدع (ج٦/ ص٨٢).

٧- المبدع (ج٦/ ص٨١).

٨- سورة البقرة:(آية ٢٣٠).

٩- أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" عن ابن عباس (٧/ ١٩٩). والطبراني في "الكبير" (١٠٨١٢) (١٠/ ٣٩٩) قال الطبراني: وفي سنده المديني، وهو عندي فليح بن سليمان. قال ابن حجر: وسنده ضعيف. وقال الهيثمي: رواه الطبراني عن المديني عن أبي الحويرث، ولم أعرف المديني ولا شيخه، وبقية رجاله ثقات. وأخرج الطبراني في "الأوسط" عن علي -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: "خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح، من لدن آدم إلى أن ولدني أبي وأمي". انظر: "المعجم الأوسط" (٤٧٢٨) (٥/ ٨٩). قال الهيثمي: فيه محمد بن جعفر بن محمد بن علي، صحح له الحاكم في "المستدرك"، وقد تكلم فيه، وبقية رجاله ثقات. وقال ابن حجر: في إسناده نظر.

انظر: "مجمع الزوائد" (٨/ ٢٨٠)، و"التلخيص الحبير" (٣/ ١٧٦).

٣- قوله -صلى الله عليه وسلم-: "تناكحوا تكثروا، فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة"[١].

٤- قوله -صلى الله عليه وسلم-: "ملعون من نكح يده" [٢].

• قالوا: وما ورد في الشرع بمعنى عقد التزويج فلقرينة صرفته عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر، مثل: قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾[٣] فإن الخطاب هنا للأولياء. فإن معنى النكاح في هذه الآية انصرف لقرينة صرفته[٤].

القول الثالث: إنه مشترك بينهما، يعني: حقيقة في كل واحد منهما بانفراده.

• وهو وجه عند الشافعية ، قال ابن حجر: "وهذا الذي يترجح في نظري وإن كان أكثر ما يستعمل في العقد". وهو قول لبعض الحنابلة[٥]، قالوا: هو ظاهر ما نقل عن الإمام أحمد وقالوا: والأشبه بأصولنا ومذهبنا أنه حقيقة في العقد والوطء جميعًا[٦]

١- أخرجه الشافعي بزيادة: "حتى بالسقط"، بقوله: بلغني. انظر: "الأم" (ج٥/ ص٢١٣)، ومن طريقه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" (ج٥/ ص٢١٩). وأخرجه عبد الرزاق مرسلًا عن سعيد بن أبي هلال (١٠٣٩) (ج٦/ ص١٧٣). قال ابن حجر: وفيه محمد بن الحارث، ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني، وهما ضعيفان. انظر: "التلخيص الحبير" (ج٣/ ١١٦). وللحديث شواهد منها:
حديث أنس بن مالك، ومعقل بن يسار، أخرجها بلفظ: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم"، أبو داود (٢٠٥٠) (٢/ ص٢٢٠)، والنسائي (٣٢٢٧) (٦/ ص٤٩)، والحاكم في "المستدرك" (ج٢/ ١٦٢). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وأقره الذهبي.

٢- أخرجه ابن الجوزي بسنده عن مسلمة بن جعفر عن حسان بن حميد عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يجمعهم مع العالمين ويدخلهم النار أول الداخلين. . . " الحديث، وذكر منهم: "الناكح يده".
قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؛ لأن فيه حسانًا، ومسلمة، لا يعرفان. قال ابن حجر: وإسناده ضعيف. انظر: "العلل المتناهية" (ج٢/ ص٦٣٣)، و"التلخيص الحبير" (ج٣/ ص١٨٨).

٣- سورة النور: (آية ٣٢)

٤ -المبسوط" (ج٤/ ص١٩٢) شرح النووي على مسلم (ج٩/ ص١٤٥) ، وفتح الباري (ج٣/ ١٠٣)

٥- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ج٨/ ص٥) ، و"المبدع" (ج٦/ ٨٢).

٦- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ج٨/ ص٥)

• دليل هذا القول: أنه ثبت في اللغة وفي الشرع استعمال لفظ النكاح بمعنى العقد والوطء، والأصل في الإطلاق الحقيقة[١].

القول الرابع: إنه حقيقة فيهما معًا، فلا يقال حقيقة على أحدهما بانفراده؛ بل على مجموعهما، فهو من الألفاظ المتواطئة[٢].

• وبهذا قال بعض الحنفية[٣] ، وبعض الحنابلة. قال ابن رزين[٤] من الحنابلة: والأشبه أنه حقيقة في كل واحد باعتبار الضم [٥].

• دليل هذا القول: أن التواطؤ خير من الاشتراك والمجاز، لأنهما على خلاف الأصل[٦] . ونقل المرداوي عن الشيخ ابن تيمية: "هو في الإثبات لهما، وفي النهي لكلٍ منهما، بناءً أنه إذا نهى عن شيء نهى عن بعضه، والأمر به أمر بكله في الكتاب والسنة والكلام. فإذا قيل مثلًا: أنكح ابنة عمّك. كان المراد العقد والوطء، وإذا قيل: لا تنكحها. تناول كل واحد منهما[٧].

• والفرق بين الاشتراك والتواطؤ: أن الاشتراك يقال على كل واحد منهما بانفراده حقيقة، بخلاف المتواطئ؛ فإنه لا يقال حقيقة إلا عليهما مجتمعين لا غير[٨].

١- فتح القدير (ج٣/ ١٨٥).

٢- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ج٨/ ص٥).

٣- فتح القدير (ج٣/ ص١٨٥) ، و"البحر الرائق" (ج٣/ص ٨٢).

٤- هو أبو الفرج عبد الرحمن بن رزين الغساني الدمشقي. سمع بدمشق وبغداد، وكان فقيهًا فاضلًا، صنف تصانيف؛ منها: "التهذيب في اختصار المغني"، وله أيضًا: "مختصر الهداية"، قتله التتار في بغداد سنة (٦٥٦ هـ). انظر في ترجمته: "المنهج الأحمد" (٣/ ٦١).

٥- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ج٨/ ٥).

٦- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ج٨/ ٥).

٧- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ج٨/ ص٦).

٨- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ج٨/ ٥ - ٦).

• هذا أهم ما قيل في حقيقة النكاح عند أهل اللغة، وعند الفقهاء، ويلاحظ أن كلام الفقهاء لم يخرج عن المدلول اللغوي لحقيقة النكاح.

• الترجيح: والذي يمكن أن يقال في خلاصة هذا المبحث أن النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وهو قول الجمهور؛ لما يلي:

١ – أن قول الحنفية ومن وافقهم، بأنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد، واستدلالهم باللغة في كثرة استعماله، فيقال فيه هنا: ما ذهبتم إليه صحيح، وقد ورد كلا الاستعمالين في اللغة، إلا أنه قد كثر استعماله حقيقة في العقد دون الوطء، فيحمل على ما كثر استعماله وهو العقد[١] .

٢ – أما قول من يرى أنه مشترك، أو أنه من الألفاظ المتواطئة، فهذا مردود؛ لأن الاشتراك اللفظي خلاف الأصل[٢].

٣ – أن استعمال لفظ النكاح على العقد هو الأشهر في القرآن والسنة وعُرف الصحابة، وأشعار العرب[٣] ، ويكفي هذا دليلًا لترجيحه.

٤ – أن التزويج لما كان بالإجماع اسمًا للعقد حقيقة، كان النكاح بمنزلته؛ لاشتراكهما في المعنى[٤] .

٥ – لو قُدِّر كونه مجازًا في العقد لكان اسمًا عرفيًّا، يجب صرف اللفظ عند الإطلاق إليه؛ لشهرته، كسائر الأسماء العرفية[٥].

٦ – أن النكاح يسمى في حق من لا يستطيع الوطء عقدًا؛ كالعنين، والكبير، والصغير، ونحو ذلك.

١- لمغني (ج٩/ ٣٤٠).
٢- المغني (٩/ ٣٣٩) ، و"المبدع" (٦/ ٨٢).
٣- الحاوي (١١/ ٩) ، و"المغني" (٩/ ٣٣٩) ، و"المبدع" (٦/ ٨٢).
٤- الحاوي (١١/ ٩).
٥- المغني (٩/ ٣٤٠) ، و"المبدع" (٦/ ٨٢).

المبحث الثالث:أدلة مشروعية النكاح وحكمته

المطلب الأول: أدلة مشروعية النكاح

لقد شرع الإسلام الزواج، وضع له نظاماً محكماً يقوم على أقوى المبادئ وأضمنها لصيانة المجتمع، وسعادة الأسرة، وانتشار الفضيلة، وحفظ الأخلاق، وبقاء النوع الإنساني والأصل في مشروعية النكاح: الكتاب والسنة والإجماع.

فأما الكتاب فقد دل على مشروعية النكاح آيات كثيرة: منها:

١- قوله تعالى: **(فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)**[١]

٢- قوله تعالى: **(وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ)**[٢]

الأيامى: جمع أيّم، وهو من لا زوج له من الرجال، ومن لازوج لها من النساء

٣- وقوله تعالى **(وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ)**[٣]

١- سورة النساء (أية: ٣)

٢ - سورة النور (آية:٣٢)

٣ - سورة الروم (آية: ٢١)

وأما السنة فقد دل على مشروعية النكاح أحاديث كثيرة: منها:

١- حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: (يا معشر الشباب، مَن استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء)[١]

الباءة: النكاح والتزوج، والمقصود هنا: تكاليف الزواج ومؤنه.

٢- عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: (تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم الأمم) [٢]

٣- وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي ﷺ يسألون عن عبادة النبي ﷺ، فلما أُخبروا كأنهم تقالُّوها، فقالوا: وأين نحن من النبي ﷺ؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال أحدهم: أما أنا فإني أُصلّي الليل أبدًا. وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أُفطِر. وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا. فجاء رسول الله ﷺ فقال: "أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر، وأُصلّي وأرقد، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني"

ونقل الإجماع على مشروعية النكاح جمع من أهل العلم منهم: ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "والأصل في مشروعية النكاح الكتاب والسنة والإجماع"[٣]

١- أخرجه البخاري (٥٠٦٦) (ج٦/ ص١٤٣) ، ومسلم (١٤٠٠) "شرح النووي" (ج٩/ ص١٤٦).

٢- رواه أبو داود برقم (٢٠٣٥) ، والنسائي برقم (٦٥١٦) وصححه الألباني، انظر: (صحيح النسائي رقم ٣٠٢٦).

٣- المغني (ج٩/ ص٣٤٠).

المطلب الثاني: حكمة مشروعية النكاح

لقد شرع الله سبحانه وتعالى النكاح لحكم سامية أجلّ من أن توصف، وأشهر من أن تذكر، وأكثر من أن تحصر، ومع هذا لا بأس من ذكر بعضها، فمن ذلك:

١- أن اللَّه سبحانه وتعالى قدّر بقاء الناس إلى قيام الساعة، ولا يكون هذا البقاء إلا بالتناسل، وجرت سنة اللَّه في خلقه أن التناسل لا يكون إلا بين الذكور والإناث، فشرع الوطء؛ ولا يكون إلا بطريق النكاح.

٢- لو لم يكن هناك نكاح بين الذكر والأنثى بالطريقة التي شرعها اللَّه سبحانه وتعالى لأدى ذلك إلى اشتباه الأنساب واختلاطها.

٣- وقد يقول قائل: قد يبقى النوع الإنساني بدون النكاح المشروع.

فيجاب عن ذلك: إن هذا يؤدي إلى ضياع الأطفال؛ لأن الأم قد تعجز عن القيام بمهام أبنائها الذين هم من آباء شتى، وهذا يؤدي أيضًا إلى اختلاط الأنساب.

٤- إخراج الماء الذي يضر احتباسه بالبدن، ونيل اللذة، وهذه الأخيرة هي التي تكون في الجنة؛ إذ لا تناسل هناك ولا احتباس.

٥- أن كل عاقل يحب أن يبقى اسمه، ولا يُمحى رسمه، ولا يكون ذلك إلا ببقاء النسل الذي لا يكون إلا بالنكاح.

الفصل الثاني

حكم النكاح وأركانه وشروطه وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: حكم النكاح.

المبحث الثاني: أركان النكاح وفيه مطلبان

- **المطلب الأول: تعريف الركن لغة واصطلاحا.**
- **المطلب الثاني: أركان النكاح عند المذاهب الأربعة**

المبحث الثالث: شروط النكاح وفيه أبعة مطالب:

- **المطلب الأول: شروط إنعقاد الزواج**
- **المطلب الثاني: شروط صحة الزواج**
- **المطلب الثالث: شروط النفاذ**
- **المطلب الرابع: شروط اللزوم**

المبحث الأول: حكم النكاح

حكم النكاح

للنكاح أحكام متعددة، وليس حكماً واحداً، وذلك تبعاً للحالة التي يكون عليها الشخص، وإليك بيان ذلك:

١- يكون النكاح واجبًا: إذا قدر على مؤنة الزواج، وخاف على نفسه الزنى، ولا يستطيع الاحتراز منهبالصوم، وغلب على ظنه عدم ظلمه للمرأة، وقدرته على أداء الحقوق والواجبات، وترك الحرام واجب، وهو الزنى، ولا يكون إلا بالنكاح، فوجب بحقه.

٢- يكون النكاح حرامًا: إذا كان الشخص لا يخشى على نفسه الزنى، وتيقن أنه سيظلم المرأة بسبب عدم قدرته على أداء حقوقها الجسدية والمادية، أو كان سببًا في ترك الفرائض والواجبات، فيحرم النكاح في حقه.

٣- يكون النكاح مكروهًا: إذا ظن أنه سيظلم زوجته، أو خاف التقصير في أداء الحقوق الزوجية، ونفسه غير تائقة للنكاح، ولا يخشى الوقوع في الزنى.

٤- يكون الزواج مباحًا: إذا كان غير تائق للنكاح ولا يخاف الزنى، وتيقن عدم ظلم المرأة، وكان زواجه للأنس والألفة، وعلمت المرأة ذلك؛ ككبير السن.

٥- يكون الزواج مندوبًا: إذا كانت نفسه تتوق للنكاح، ولا يخاف الوقوع في الزنى، ولا يخاف ظلم المرأة وعدم قدرته على الحقوق والواجبات.[١]

١- إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، لابن دقيق، (ص٧٦٦) ، والقوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية، لابن جزي،(ص ٣٢٦).

المبحث الثاني: أركان النكاح

المطلب الأول: تعريف الركن لغة واصطلاحا.

الركن في اللغة: الجانب الأقوى من كل شيء يقال: ركنت إلى الله أي اعتمدت عليه، والركن العز والمنعة، ومنه قوله تعالى: ﴿**قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ**﴾[1]

والركن في الاصطلاح: هو الداخل في حقيقة الشيء المحقق لماهيته، وقيل: هو: ما يتم به الشيء، وهو داخل فيه[2].

فالركن يخالف الشرط فهو داخل في ماهيته الشيء كالركوع بالنسبة للصلاة والشرط ما توقف الشيء على وجوده وليس جزءا منه كالضوء بالنسبة للصلاة.

عرفه ابن نجيم: بأن الركن، هو جزء الماهية[3].

وعرفه بعض المالكية: ما تحقق به الماهية، ولو لم يكن جزءًا منها حقيقة[4].

وعرفه بعض الشافعية: بأن أركان الشيء: أجزاؤه في الوجود، التي لا يحصل إلا بحصولها، داخلةً في حقيقته، محققةً لهويته[5].

١- سورة هود (الآية: ٨٠)

٢- أنظر: الْمُهَذَّبُ فِي عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ الْمُقَارَنِ (ج٥/ص ١٩٦٣)

٣- البحر الرائق (ج١/ ص٣٠٦).

٤- الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (ج٢/ ص٥٤٢).

٥- أسنى المطالب في شرح روض الطالب (ج١/ ص١٤١).

المطلب الثاني: أركان النكاح عند المذاهب الأربعة

اختلف الفقهاء في أركان النكاح على عدة أقوال[1]:

الأول: أن ركنه واحد الإيجاب والقبول وهو مذهب الحنفية.

التاني: أن أركانه ثلاثة وهي عند المالكية الولي، الزوجان، والصيغة.

الثالث: وعند الحنابلة الزوجان والإيجاب والقبول.

الرابع: أركانه خمسة وهو مذهب الشافعية وهي: الصيغة، والزوج، والزوجة، والشاهدان، والولي.

تفصيل في أركان النكاح

أولًا: الزوجان الخاليان من الموانع: لا خلاف بين الفقهاء أن النكاح لا ينعقد إلا بين زوجين خاليين من الموانع شرعًا، والموانع الشرعية هي العلاقة التي جعلها الشارع سببا لتحريم النكاح بين الرجل والمرأة إما على سبيل التأبيد أو إلى أجل.

ثانيا:الصيغة في النكاح: اتفق الفقهاء على أن النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول، وذلك باللفظ الذي يدل على ذلك، وما يقوم مقام اللفظ.

١- بدائع الصنائع (ج٢/ ص٢٢٩) ، الشرح الصغير (ج٣/ ص٨١ - ٨٢) ، مغني المحتاج (ج٣/ ص١٣٩) ، كشاف القناع (ج٥/ ص٣٧).

أما الإيجاب فعند جمهور الفقهاء – المالكية والشافعية والحنابلة – هو ما يصدر من ولي الزوجة، والقبول هو ما يصدر من الزوج أو وكيله.

لكن المالكية والشافعية يستوي عندهم أن يتقدم القبول على الإيجاب أو يتأخر عنه ما دام قد تحدد الموجب والقابل، فلو قال الزوج للولي: زوجني أو تزوجت بنتك كان قبولا، ولو قال الولي بعد ذلك: زوجتك أو أنكحتك كان إيجابا، وانعقد النكاح بذلك.

إلا أن المالكية قالوا: يندب تقدم الإيجاب[1].

أما عند الحنابلة فلا بد أن يتقدم الإيجاب على القبول ولا يجوز أن يتقدم القبول عليه، قالوا: لأن القبول إنما يكون للإيجاب، فمتى وجد قبله لم يكن قبولا لعدم معناه فلم يصح، فلو قال الزوج: تزوجت ابنتك، وقال الولي: زوجتكها، لم يصح رواية واحدة[2].

وأما الحنفية فالإيجاب عندهم هو ما يصدر أولا، سواء أكان المتقدم هو كلام الزوج أم كان كلام الزوجة أو وليها، والقبول هو ما يصدر مؤخرا، سواء أكان صدوره من الزوج أم كان من الزوجة أو وليها. وعلى هذا لو قال الزوج: زوجني أو تزوجت بنتك كان إيجابا، فلو قال الولي أو الزوجة: قبلت كان قبولا، وينعقد النكاح بذلك[3]. ولا يصح إضافة صيغة النكاح إلى المستقبل كأن يقول الرجل للمرأة: تزوجتك غدا أو بعد غد أو سنة كذا أو شهر كذا، أو زوجتك ابنتي إذا جاء رأس الشهر[4].

١- الشرح الكبير وحاشية الدسوقي (ج٢ / ص٢٢١) ، ومغني المحتاج (ج٣ / ١٤٠)

٢- المغني (ج٦ / ٥٣٤) ، وكشاف القناع (ج٥ / ٣٧)

٣- فتح القدير لابن همام (ج٣ / ص١٠٢)

٤- مغني المحتاج (ج٣ / ١٤٢) ، وكشاف القناع (ج٥ / ٩٧، ٩٨).

ثالثا: الولي: اختلف الفقهاء في كون الولي ركنا من أركان النكاح أو شرطا في صحته أو شرطا في جوازه ونفاذه.

فقال المالكية والشافعية: الولي ركن من أركان عقد النكاح، فلا يصح النكاح بدون ولي بشروطه، لأنه من أركان العقد التي لا يتحقق وجوده إلا بها، والمراد بالولي من له ولاية ولو تولى العقد غيره بإذنه. ولا يصح عند المالكية والشافعية تولي عقد النكاح من أنثى[1].

فلا تصح عبارة المرأة في النكاح إيجابا وقبولا، فلا تزوج نفسها بإذن الولي ولا بغير إذنه، ولا غيرها لا بولاية ولا بوكالة، ولا تقبل النكاح لا بولاية ولا بوكالة. وقال الشافعية: ولو عدم الولي والحاكم فولت مع خاطبها أمرها رجلا مجتهدا ليزوجها منه صح لأنه محكم، والمحكم كالحاكم، وكذا لو ولت معه عدلا صح على المختار وإن لم يكن مجتهدا لشدة الحاجة إلى ذلك قال في المهمات: ولا يختص ذلك بفقد الحاكم بل يجوز مع وجوده سفرا وحضرا بناء على الصحيح في جواز التحكيم، قال الولي العراقي: ومراد المهمات ما إذا كان المحكم صالحا للقضاء، وأما الذي اختاره النووي أنه يكفي العدالة ولا يشترط أن يكون صالحا للقضاء فشرطه السفر وفقد القاضي[2].

١- الشرح الصغير م٢ / ٣٣٥ ، وشرح الزرقاني ٣ / ١٦٨، ومغني المحتاج ٣ / ١٤٧.

٢- عقد الجواهر الثمينة ٢ / ١٣، ومغني المحتاج ٣ / ١٤٧.

وقال الحنفية: الولاية شرط في الركن وهي من شروط الجواز والنفاذ، فلا ينعقد إنكاح من لا ولاية له، والولي: العاقل البالغ الوارث، فخرج الصبي والمعتوه والعبد والكافر على المسلمة، وهذا عند أكثر فقهائهم، وقال الرملي وابن عابدين: التعريف خاص بالولي من جهة القرابة، إذ الحاكم ولي وليس بوارث وكذا سيد العبد.

والولاية في النكاح نوعان:

الأول: ولاية ندب واستحباب، وهو الولاية على البالغة العاقلة بكرا كانت أو ثيبا.

والثاني: ولاية إجبار، وهو الولاية على الصغيرة بكرا كانت أو ثيبا، وكذا الكبيرة المعتوهة والمرقوقة.

رابعا: الإشهاد على النكاح: اختلف الفقهاء في كون الإشهاد على النكاح: ركنا أو شرطا أو واجبا فقال جمهور الفقهاء – الحنفية والشافعية والحنابلة لا يصح النكاح إلا بحضرة شاهدين لخبر عائشة رضي الله تعالى عنها " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل "[1] ، والمعنى في اعتبارهما الاحتياط للأبضاع، ولأنه عقد يتعلق به حق غير المتعاقدين، وهو الولد، فاشترطت الشهادة فيه لئلا يجحده أبوه فيضيع نسبه، ولأن الحاجة ماسة إلى دفع تهمة الزنا عن الزوجة بعد النكاح والدخول، ولا تندفع إلا بالشهود لظهور النكاح واشتهاره بقول الشهود.

غير أن الحنفية والحنابلة يرونه شرطا، ويرى الشافعية أنه ركن[2] وفي رواية عن أحمد أن الشهادة ليست من شروط النكاح،.

١- حديث: " لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ". أخرجه ابن حبان في صحيحه (ج٩ / ص٣٨٦) د/ مؤسسة الرسالة ، والبيهقي في السنن الكبرى (ج٧ / ص١٢٤) ط/دار المعارف العثمانية.

٢- بدائع الصنائع (ج٢ / ص٢٥٣) ، ومغني المحتاج (ج٣ / ص١٤٤).

وقيد المجد وجماعة من الأصحاب بما إذا لم يكتموه فمع الكتم تشترط الشهادة رواية واحدة، وذكره بعضهم إجماعا[1] وقال المالكية: الإشهاد على النكاح واجب، ولكنه ليس ركنا من أركان عقد النكاح لأن ماهية العقد لا تتوقف عليه، وهو كذلك ليس شرطا في صحة عقد النكاح، بل هو واجب مستقل، مخافة أن كل اثنين – رجل وامرأة – اجتمعا في خلوة على فساد يدعيان سبق عقد بلا إشهاد فيؤدي إلى رفع حد الزنا.

وأصل الإشهاد على النكاح عند المالكية واجب، وكونه عند العقد زيادة على الواجب، فإن حصل الإشهاد عند العقد فقد حصل الواجب والمندوب، وإن فقد عند العقد ووجد عند الدخول فقد حصل الواجب وفات المندوب، وإن لم يحصل عند العقد كان واجبا عند البناء، وإن لم يوجد شهود أصلا وحصل الدخول بلا إشهاد على النكاح فسخ العقد بطلقة بائنة، وإنما كان الفسخ بطلقة لصحة العقد بدون الإشهاد عليه، وكان ببائنة لأنه فسخ جبري من الحاكم[2].

واتفق الفقهاء على أنه يلزم توفر شروط في شاهدي النكاح وهي: الإسلام والتكليف والعدالة والعدد والحرية والذكورة والسمع والبصر والنطق والتيقظ ومعرفة لسان العاقدين وأن لا يكون الشاهدان ابني الزوجين[3]

١- الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (ج٨ / ص١٠٢) ، والمغني (ج٦ / ص٤٥١).

٢- الشرح الصغير والصاوي (ج٢ / ٣٣٩).

٣- الموسوعة الفقهية الكويتية (ج٤١/ ص ٢٩٦)

المبحث الثالث: شروط النكاح

تعريف الشرط

الشرط في لغة: بسكون الراء وهو إلزام الشيء والتزامه في البيع ونحوه. جمعه شروط. تقول: شرط له أمرا: التزمه وعليه أمرا: ألزمه إياه[1].

وفي الاصطلاح: ما يتوقف ثبوت الحكم عليه[2].

وقيل: ما لا يوجد المشروط مع عدمه ولا يلزم أن يوجد عند وجوده[3].

وقيل: ما يتوقف عليه صحة شروطه[4]

وقيل: ما توقف الشيء على وجوده ولم يكن جزءا من حقيقته[5]. كالوضوء في الصلاة. فإنه شرط لصحة الصلاة. فإذا لم يوجد لم تصح الصلاة، وليس الوضوء جزءا من حقيقة الصلاة. وهكذا كل ما جعله الشارع شرطا لشيء. فإن هذا الشيء لا يتحقق ولا يعتد به – في نظر الشارع إلا إذا تحقق ذلك الشرط وإن لم يكن جزءا من حقيقته ٥وهذا التعريف: هو الأولى، لأنه يتضمن ما أشارت إليه التعاريف السابقة وعليه: فشروط الشيء هي التي لا يصح إلا بتوافرها.

١- انظر: معجم متن اللغة مادة شرط (ج٣/ ص ٣٠٤) ، والمعجم الوسيط مادة شرط (ج/١ ص ٤٧٨).

٢- التعريفات (ص ١٣١).

٣- روضة الناضر (ص ١٣٥).

٤- إتحاف المسلمين بما تيسر من أحكام الدين (ج١ / ص ١٢٢).

٥- أصول الفقه الإسلامي (ص ٣١٥).

المطلب الأول: شروط إنعقاد الزواج

يشترط لانعقاد الزواج شروط في العاقدين ـ الرجل والمرأة[1].

أولاً ـ شروط العاقدين: يشترط في عاقدي الزواج شرطان:

١- أهلية التصرف: أن يكون العاقد لنفسه أو لغيره أهلاً لمباشرة العقد، وذلك بالتمييز فقط، فإذا كان غير مميز كصبي لم يبلغ السابعة ومجنون، لم ينعقد الزواج؛ ويكون باطلاً؛ لعدم توافر الإرادة والقصد الصحيح المعتبر شرعاً.

ولا يشترط البلوغ لانعقاد الزواج وصحته، وإنما هو شرط لنفاذ العقد عند الحنفية.

وأجاز الشافعية للولي من أب أو جد تزويج صغير مميز ولو أكثر من واحدة إن رآه الولي مصلحة؛ لأن تزويجه بالمصلحة؛ وقد تقتضي ذلك [2]. وأجاز الحنابلة[3] أيضاً للأب خاصة تزويج ابنه الصغير أو المجنون ولو كان كبيراً، وأجاز المالكية[4] للأب والوصي والحاكم تزويج المجنون والصغير لمصلحة كالخوف من الزنا أو الضرر، أو ممن تحفظ له ماله، والصداق على الأب.

٢- سماع كلام الآخر: أن يسمع كل من العاقدين لفظ الآخر، ولو حكماً كالكتاب إلى امرأة غائبة، ويفهم أن المقصود منه إنشاء الزواج، ليتحقق رضاهما به. والأدق أن يعتبر هذا شرطاً في صيغة العقد.

ولا يشترط عند الحنفية توافر حقيقة الرضا، فيصح الزواج مع الإكراه والهزل.

١- البدائع (ج٢/ ص٢٣٢) الدر المختار ورد المحتار: (ج٢/ ص٣٦٦، ٣٦٧، ٣٧٣).

٢- مغني المحتاج: (ج٣/ ص١٦٩) ، المهذب: (ج٢/ ص٤٠).

٣- كشاف القناع: (ج٥ / ص٤٤،٤٣)

٤- الشرح الصغير: (ج٢/ ص٣٩٦)

ثانياً . شروط المرأة: يشترط في المرأة لأجل عقد الزواج شرطان:

١- أن تكون أنثى محققة الأنوثة: فلا ينعقد الزواج على الرجل أو الخنثى المشكل: وهو الذي لا يستبين أمره، أهو رجل أم أنثى، ويكون الزواج على خنثى باطلاً.

٢- ألا تكون محرَّمة على الرجل تحريماً قاطعاً لا شبهة فيه: فلا ينعقد الزواج بالمحارم كالبنت والأخت والعمة والخالة، والمتزوجة بزوج آخر، والمعتدة، والمرأة المسلمة بغير المسلم، والزواج في كل هذه الحالات باطل.

المطلب الثاني: شروط صحة الزواج:

يشترط لصحة الزواج عشرة شروط، بعضها متفق عليه، وبعضها مختلف فيه .

الأول . المحلية الفرعية، ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤقتاً، أو تحريماً فيه شبهة، أو خلاف بين الفقهاء، كتزويج المعتدة من طلاق بائن، وتزوج أخت المطلقة التي لا تزال في العدة، والجمع بين اثنتين كلتاهما محرم للأخرى، كتزوج العمة على ابنة أخيها، والخالة على ابنة أختها، فإذا لم تتحقق هذه المحلية الفرعية كان العقد فاسداً عند الحنفية.

أما المحلية الأصلية: وهي ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً، كالأخت والبنت والعمة والخالة، فهي شرط لانعقاد الزواج، فإذا لم تتحقق هذه المحلية، كان العقد باطلاً بالاتفاق، ولا يترتب عليه أي أثر من آثار الزواج وعلى هذا إذا كان التحريم قطعياً، كان سبباً من أسباب البطلان، وإذا كان التحريم ظنياً، كان سبباً من أسباب الفساد عند الحنفية.

الزواج في حال انعدام المحلية الفرعية فاسد، يترتب عليه بالدخول بعض الآثار، لكن يحرم الدخول بالمرأة في حال فساد العقد، ويجب فيه التفريق بين الرجل والمرأة جبراً إن لم يتفرقا اختياراً.

وإذا حصل دخول بعد هذا الزواج الفاسد بالرغم من تحريمه وكونه معصية، ووجوب التفريق، فتترتب عليه بعض الآثار، فيجب فيه للمرأة أقل الأمرين من المهر المسمى ومهر المثل، وتجب عليها العدة، ويثبت به نسب الولد إن حدث حمل، ولكن لا يثبت به حق التوارث بين الزوجين. والثاني ـ التأبيد في صيغة العقد، والثالث ـ الشهادة، والرابع ـ الرضا والاختيار، والخامس ـ تعيين الزوجين، والسادس ـ عدم الإحرام بالحج أو العمرة، والسابع ـ أن يكون بصداق، والثامن ـ عدم التواطؤ على الكتمان، والتاسع ـ ألا يكون أحد الزوجين أو كلاهما في مرض مخوف، والعاشر ـ الولي[1].

المطلب الثالث: شروط النفاذ

اشترط الحنفية لنفاذ عقد الزواج وترتب آثاره عليه بالفعل بعد انعقاده صحيحاً الشروط الخمسة التالية[2]

١- أن يكون كل من الزوجين كامل الأهلية إذا تولى عقد الزواج بنفسه، أو بوكيل عنه، وكمال الأهلية بالعقل والبلوغ والحرية، فمتى كان كل من الزوجين عاقلاً بالغاً حراً، نفذ العقد وترتبت آثاره عليه، من حل الدخول ووجوب المهر وغيرهما.

أما إن باشر عقد الزواج صبي مميز أو عبد، فيتوقف العقد عند الحنفية والمالكية على إجازة الولي من أب ونحوه، أو سيد. وإن باشره مجنون أوغير مميز فلا ينعقد أصلاً.

١- الدر المختار ورد المحتار (ج٢/ ص٣٧٣) والبدائع (ج٢/ ص٣٥١) ،

٢- البدائع: (ج٢/ ص٢٣٣)

وعند الشافعية والحنابلة: لا تنعقد تصرفات العبد والصبي المميز وغير المميز أصلاً، بل هي باطلة.

٢- أن يكون الزوج رشيداً، إذا تولى الزواج بنفسه: هذا شرط عند المالكية، فإن كان سفيهاً غير رشيد: وهو الذي لا يحسن التصرف في ماله، وتزوج بدون إذن الولي، توقف عقد زواجه عند المالكية على إجازة وليه[١].

وقال الشافعية والحنابلة[٢] : الرشد شرط لصحة الزواج، فلو تزوج السفيه بغير إذن وليه، كان الزواج باطلاً؛ لأنه تصرف يجب به مال، وفي الزواج ودفع المهر والنفقة إتلاف للمال أو مظنة إتلافه.

وقال الحنفية : ليس الرشد شرطاً لصحة الزواج ولا لنفاذه، فإن تزوج السفيه امرأة جاز زواجه؛ لأنه من حوائجه الأصلية وتصرفاته الشخصية، والحجر إنما هو على التصرفات المالية المحضة. والقاعدة عندهم: أن كل ما لا يؤثر فيه الهزل كالعتق والنكاح، لا يؤثر فيه الحجر، لكن لا يثبت للمرأة أكثر من مهر المثل إذا كان السفيه هو الزوج، ويثبت فيه مهر المثل على الأقل إذا كانت الزوجة هي السفيهة.

٣- ألا يكون العاقد ولياً أبعد مع وجود الولي الأقرب المقدم عليه: شرط نفاذ عند الحنفية، فإن زوج الولي الأبعد مع وجود الأقرب منه، كان العقد موقوفاً على إجازة الولي الأقرب.

وهو شرط صحة عند الشافعية والحنابلة[٣] ، فلا يصح زواج الولي الأبعد مع وجود الأقرب إلا إذا كان هناك مانع كالجنون واختلال النظر بهرم أو خَبَل (فساد في العقل)، والصغر، والحجر بسفه، والعضل (أي المنع من الزواج بغير حق).

١- الشرح الصغير: (ج٣/ ص٣٨٧) والشرح الكبير (ج٣/ ص٢٣١) القوانين الفقهية (ص١٩٧).

٢- مغني المحتاج (ج٢/ ص١٧١) ، كشاف القناع: (ج٢/ ص٤٤١)

٣- مغني المحتاج: (ج٣/ ص١٥٤)

وقال المالكية[1] : إن كان الولي الأقرب غير مجبر كالابن والأخ والجد والعم، كان العقد صحيحاً مكروهاً. وإن كان الأقرب ولياً مجبراً (وهو الأب) فسخ العقد أبداً، إلا إذا أجازه الولي الأقرب، وكان الذي تولاه مفوضاً إليه الأمر بالبينة.

٤- ألا يخالف الوكيل موكله فيما وكله به: فإذا وكل شخص غيره ليزوجه فتاة معينة أو بمهر معين، فزوجه فتاة غيرها، أوزوجه بمهر أكثر، لم ينفذ العقد، وكان موقوفاً على إجازة الموكل. فلو لم يعلم حتى دخل بقي الخيار له بين إجازته وفسخه، ويكون للمرأة عند الحنفية الأقل من المسمى ومهر المثل؛ لأن الموقوف كالفاسد.

٥- ألا يكون العاقد فضولياً: والفضولي: هو من لا يكون له ولاية التزويج وقت العقد. وهو شرط نفاذ عند الحنفية والمالكية. فإذا زوج شخص امرأة لرجل وقبل عنه، دون ولاية ولا وكالة عنه وقت العقد، كان الزواج موقوفاً على إجازة الزوج عندهم.

وأما عند الشافعية والحنابلة فتصرف الفضولي من بيع وزواج باطل.

المطلب الرابع:شروط اللزوم

معنى لزوم العقد: ألا يكون لأحد العاقدين أو لغيرهما حق فسخه بعد انعقاده، بأن يخلو العقد من الخيار. ويشترط للزوم الزواج أربعة شروط هي[2]:

١- الشرح الصغير: (ج٢/ ص٣٥٨- ٣٦٣)

٢- البدائع:(ج٢/ ص٣١٥-٣٢٢) والمهذب:(ج٢/ ص٣٩) وكشاف القناع: (ج٥/ ص٧١)

١- أن يكون الولي المزوج لفاقد الأهلية كالمجنون والمعتوه، أو ناقصها وهو الصغير والصغيرة: هو الأب أو الجد، وهو شرط عند أبي حنيفة ومحمد. فلو كان المزوج لهما غيرهما كالأخ والعم، كان لكل منهما حق فسخ العقد عند زوال المانع أي الإفاقة من الجنون أو العته، والبلوغ بعد الصغر، حتى ولو كان الزواج بالكفء وبمهر المثل[١] ؛ لأن قرابة غير الأصل والفرع قرابة حواشي، فلا يساوون الأصل والفرع بالشفقة، فيقدر زواجهم بالمصلحة الظاهرة، ويعطى المتزوج خيار الفسخ.

ودليل أبي حنيفة ومحمد: ما روي أن قدامة بن مظعون زوَّج بنت أخيه: عثمان بن مظعون، من عبد الله بن عمر رضي الله عنه، فخيرها رسول الله صلّى الله عليه وسلم بعد البلوغ، فاختارت نفسها، حتى روي أن ابن عمر قال: إنها انتزعت مني بعد ما ملكتها.

وقال أبو يوسف: ليس هذا بشرط، ويلزم نكاح غير الأب والجد من الأولياء، فلا يثبت الخيار للمولى عليه؛ لأن هذا النكاح صدر من ولي، فيلزم، كما إذا صدر عن الأب والجد، لأن ولاية التزويج ولاية نظر في حق المولى عليه، وقد اجتهد الولي في تحقيق المصلحة، ونظر فيما هو الأولى والأصلح.

فإذا زوج الحاكم فاقد الأهلية أو ناقصها، فلا خيار للمولى عليه في رأي أبي حنيفة خلافاً لمحمد؛ لأن ولاية الحاكم أعم من ولاية الأخ والعم؛ لأنه يملك التصرف في النفس والمال، فكانت ولايته شبيهة بولاية الأب والجد، وولايتهما ملزمة، فتلزم ولاية الحاكم.

١- الكفء لغة: المساوي لغيره والمماثل له، واصطلاحاً: أن يساوي الرجل زوجته في أمور الدين والحرية والمال والحرفة. ومهر المثل: هو المهر الذي تتزوج به امرأة من أقارب أبي الزوجة، وتماثلها وقت العقد في صفات مخصوصة.

٢- أن يكون الزوج كفئاً للزوجة إذا زوجت المرأة الحرة البالغة العاقلة نفسها من غير رضا الأولياء بمهر مثلها، وكان لها ولي عاصب[١] لم يرض بهذا الزواج، فلهذا الولي طلب فسخ الزواج من القاضي. وهذا شرط عند الحنفية في ظاهر الرواية.

وكذلك قال أئمة بقية المذاهب: الكفاءة في الزوج شرط للزوم الزواج، لا لصحته، فيصح النكاح مع فقدها، وهي حق للمرأة والأولياء كلهم القريب والبعيد، لتساويهم في لحوق العار بفقد الكفاءة، فلو زوجت المرأة بغير كفء، فلمن لم يرض بالنكاح الفسخ، فوراً أو تراخياً، سواء من المرأة أو الأولياء جميعهم؛ لأنه خيار لنقص في المعقود عليه كخيار البيع، ويملكه الأبعد من الأولياء مع رضا الأقرب منهم به، ومع رضا الزوجة، دفعاً لما يلحقه من لحوق العار.

والدليل على أن الكفاءة شرط لزوم لا شرط صحة أنه صلّى الله عليه وسلم: «أمر فاطمة بنت قيس أن تنكح أسامة بن زيد مولاه، فنكحها بأمره» (١) وروت عائشة «أن أبا حذيفة ابن عقبة بن ربيعة تبنى سالماً، وأنكحه ابنة أخيه: الوليد بن عقبة، وهو مولى لامرأة من الأنصار» (٢) وعن أبي حنظلة بن أبي سفيان الجمحي عن أمه قالت: «رأيت أخت عبد الرحمن بن عوف تحت بلال» (٣).

٣- أن يكون المهر بالغاً مهر المثل إذا زوجت الحرة العاقلة البالغة نفسها من غير كفء، بغير رضا الأولياء، وألا يقل عن مهر المثل إذا زوجت المرأة نفسها من كفء. وهذا عند أبي حنيفة، فللأولياء حق الاعتراض وطلب فسخ الزواج، إلا إذا قبل الزوج زيادة المهر إلى مهر المثل، فلا يكون للولي حينئذ حق الفسخ، وبناء عليه إما أن يزيد الزوج إلى مهر المثل أو يفرق بينهما.

١- الولي العاصب: هو القريب الذي لا تكون قرابته للمرأة بواسطة الأنثى وحدها، كالأب والجد وأبي الأب، والأخ والعم وابن العم.

وعند أبي يوسف ومحمد: ليس هذا بشرط، ويلزم النكاح بدونه.

٤- خلو الزوج عن عيب الجب والعنة عند عدم الرضا من الزوجة بهما.

الفصل الرابع

- خاتمة البحث
- نتائج البحث
- توصيات البحث
- الفهارس

خاتمة البحث

الحمد لله الذي وفقني في تقديم هذا البحث، وها هي القطرات الأخيرة في مشوار هذا البحث، أذكركم ونفسي بتقوى الله، وبالعمل الصالح لوجه الله تعالى قد أكملت هذا البحث ببركة الله وعونه وفضله وتوفيقة، وقد أكرمني الله بأن أدلوا بدلوي تجاه هذا الموضوع (النكاح حقيقته أركانه وشروطه) وفي نهاية الأمر فإنني بشر أصيب وأخطئ، وإنني أتوجه إلى الله بالدعاء على توفيقي في تقديم هذا البحث والحمد لله الذي هدانا. وصل اللهم على حبيبنا وسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيراً.

ومن النتائج التي توصل إلى ما يلي:

أولا: تعريف النكاح: **وهو عقد شرعي يحل به استمتاع كل من الزوجين بالآخر**.

ثاني: بعد التتبع والإستقراء عرفنا أن أن النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء

توصيات البحث

١-الحرص على الكلام العاطفي اللين الرقيق بين الزوجين ، واستخدام المفردات التي تدلّ على المحبّة والألفة والمودّة، وكذلك يجب الحرص على المفردات التي تدلّ على الاحترام المتبادل بين الطرفين،

٢- عدم البخل بالعبارات والألفاظ التي تدلّ على الحبّ والمودّة، واشتياق كلّ طرفٍ للآخر، والتعبير عن سعادة كلٍّ منهما بلقاء الطرف الآخر، والحرص على ذكر الصفات الحسنة الخَلقية والخُلقية.

٣-احترام كلّ طرفٍ من أطراف العلاقة الزوجيّة لآراء وأفكار ومشاعر الطرف الآخر

وبهذ قد انتهت كتابة البحث، وأدعو الله بالتوفيق لي ولكم.

الفهارس

المصادر والمراجع

القرءان

١- القرءان الكريم

٢- أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي (المتوفى: ٦٧١هـ) الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش دار: الكتب المصرية – القاهرة الطبعة: الثانية، عدد الأجزاء: ٢٠ جزءا (في ١٠ مجلدات)

مراجع عامة

١- محمد بن أحمد بن الأزهري (تهذيب اللغة) د/ إحياء التراث العربي – بيروت، الطبعة : الأولى

٢- محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى (المتوفى: ٧١١هـ) (لسان العرب) د: دار صادر – بيروت ط: الثالثة عدد الأجزاء: ١٥

٣- أحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، أبو العباس (المتوفى: نحو ٧٧٠هـ) (المصباح المنير في غريب الشرح الكبير) د: المكتبة العلمية – بيروت عدد الأجزاء:٢ بدون طبعة.

٤- محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى، الزَّبيدي (المتوفى: ١٢٠٥هـ) (تاج العروس من جواهر القاموس) المحقق: مجموعة من المحققين الناشر: دار الهداية، بدون طبعة.

٥- محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور (المتوفى: ٣٧٠هـ) (تهذيب اللغة) المحقق: محمد عوض مرعب د: دار إحياء التراث العربي – بيروت ط:١ عدد الأجزاء: ٨ بدون طبعة.

٦- مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى (المتوفى: ٨١٧هـ) (القاموس المحيط) تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة د: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الثامنة.

٧- منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى الحنبلى (المتوفى: ١٠٥١هـ) (كشاف القناع عن متن الإقناع) د: دار الكتب العلمية عدد الأجزاء:٦، بدون طبعة.

٨- كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام (المتوفى: ٨٦١هـ) (فتح القدير) الناشر: دار الفكر عدد الأجزاء: ١٠، بدون طبعة.

٩- أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي (المتوفى: ١٢٤١هـ) (بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير) الناشر: دار المعارف عدد الأجزاء:٤ بدون طبعة.

١٠- زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي (المتوفى: ٩٢٦هـ) (فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب) الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر، بدون طبعة.

١١- علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد المِرْداوي (المتوفى: ٨٨٥ هـ) (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف) تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي - الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة: الأولى، عدد الأجزاء: ٣٠.

١٢- عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (المتوفى: ٩١١هـ) (الأشباه والنظائر) الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى.

١٣- زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: ٩٧٠هـ) (الأشباه والنظائر) الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة: الأولى.

١٤- شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي (المتوفى: ٩٧٧هـ) (مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج) الناشر: دار الكتب العلمية الطبعة: الأولى، عدد الأجزاء: ٦.

١٥- شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (المتوفى: ٦٢٦هـ) (معجم الأدباء) المحقق: إحسان عباس الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت الطبعة: الأولى، عدد الأجزاء: ٧

١٦- زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي (المتوفى: ٦٦٦هـ) (مختار الصحاح) المحقق: يوسف الشيخ محمد الناشر: المكتبة العصرية الطبعة: الخامسة.

١٧- أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (المتوفى: ٨٥٢هـ) (الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة) المحقق: مراقبة / محمد عبد المعيد ضان الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية – صيدر اباد/ الهند الطبعة: الثانية، عدد الأجزاء: ٦.

١٨- محمد بن عيسى بن سَوْرة بن موسى بن الضحاك، الترمذي، أبو عيسى (المتوفى: ٢٧٩هـ) (الجامع الكبير – سنن الترمذي) المحقق: بشار عواد معروف الناشر: دار الغرب الإسلامي ، عدد الأجزاء: ٦

١٩- أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني (المتوفى: ٢٧٥هـ) (سنن أبي داود) المحقق: محمد محيي الدين عبد الحميد الناشر: المكتبة العصرية، عدد الأجزاء: ٤

٢٠- ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد (المتوفى: ٢٧٣هـ) (سنن ابن ماجه) تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء الكتب العربية عدد الأجزاء: ٢.

٢١- مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (المتوفى: ٢٦١هـ) (صحيح مسلم) المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي الناشر: دار إحياء التراث العربي ، عدد الأجزاء: ٥

٢٢- محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي (صحيح البخاري) المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر الناشر: دار طوق النجاة ، الطبعة: الأولى، عدد الأجزاء: ٩.

٢٣- محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: ١٢٥٠هـ) (نيل الأوطار) تحقيق: عصام الدين الصبابطي، الناشر: دار الحديث، مصر الطبعة: الأولى، عدد الأجزاء: ٨.

٢٤- محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (المتوفى: ٤٨٣هـ) (المبسوط) الناشر: دار المعرفة – بيروت عدد الأجزاء: ٣٠.

٢٥- زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، السَلامي، البغدادي، ثم الدمشقي، الحنبلي (المتوفى: ٧٩٥هـ) (ذيل طبقات الحنابلة) المحقق: د عبد الرحمن بن سليمان العثيمين ، الناشر: مكتبة العبيكان – الرياض، الطبعة: الأولى، عدد الأجزاء: ٥.

٢٦- إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين (المتوفى: ٨٨٤هـ) (المبدع في شرح المقنع) الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان ، الطبعة: الأولى، عدد الأجزاء:٨.

٢٧- أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي (المتوفى: ٤٥٨هـ) (السنن الكبرى) المحقق: محمد عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان ، الطبعة: الثالثة.

٢٨- جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي (المتوفى: ٥٩٧هـ) (العلل المتناهية في الأحاديث الواهية) المحقق: إرشاد الحق الأثري ، الناشر: إدارة العلوم الأثرية، فيصل آباد، باكستان ، الطبعة: الثانية، عدد الأجزاء: ٢.

٢٩- أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي(فتح الباري شرح صحيح البخاري)، الناشر: دار المعرفة – بيروت.

٣٠- عبد الكريم بن علي بن محمد النملة،(الْمُهَذَّبُ فِي عِلْمِ أُصُولِ الفِقْهِ الْمُقَارَنِ) دار النشر: مكتبة الرشد – الرياض، عدد الأجزاء: ٥.

٣١- الموسوعة الفقهية الكويتية ، صادر عن: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية – الكويت ، عدد الأجزاء: ٤٥ جزءا.

فهرس الآيات

رقم	الآيـــة	الصفحة
١	وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ	٣
٢	وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ	٥
٣	ولَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً	٨
٤	فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ	١٣
٥	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ	١٦
٦	فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ	٢٥
٧	وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا	٢٥

فهرس الموضوعات

رقم	الموضوع	الصفحة
١	**السملة**	٢
٢	**الإستهلال**	٣
٣	**الإهداء**	٤
٤	**الشكر والتقدير**	٥
٥	**حطة البحث**	٦
٦	**المقدمة**	٨
٧	سبب اختيار الموضوع	٩
٨	مشكلة البحث	٩
٩	اهمية الموضوع	٩
١٠	حدود البحث	١٠
١١	الدراسات السابقة للبحث	١٠
١٢	الفصل الأول: مفهوم النكاح وحقيقته ومشروعيته وفيه ثلاثة مباحث:	١٢
١٣	المبحث الأول:مفهوم النكاح	١٣
١٤	المبحث الثاني: حقيقة النكاح	١٨

١٥	المبحث االثالث: أدلة مشروعية النكاح وحكمته	٢٦
١٦	المطلب الأول: أدلة مشروعية النكاح	٢٦
١٧	المطلب الثاني: حكمة مشروعيته	٢٨
١٨	الفصل الثاني: حكم النكاح وأركانه وشروطه وفيه ثلاثة مباحث:	٢٩
١٩	المبحث الأول: حكم النكاح	٣٠
٢٠	المبحث الثاني: أركان النكاح وفيه مطلبان.	٣٢
٢١	المطلب الأول: تعريف الركن لغة واصطلاحا.	٣٢
٢٢	المطلب الثاني: أركان النكاح عند المذاهب الأربعة.	٣٣
٢٣	المبحث الثالث: شروط النكاح وفيه أربعة مطالب:	٣٨
٢٤	المطلب الأول: شروط إنعقاد الزواج	٣٩
٢٥	المطلب الثاني: شروط صحة الزواج	٤٠
٢٦	المطلب الثالث: شروط النفاذ	٤١
٢٧	المطلب الرابع: شروط اللزوم	٤٣
٢٨	الفصل الثالث: خاتمة البحث	٤٧
٢٩	نتائج البحث	٤٨

٣٠	توصيات البحث	٤٨
٣١	الفهارس	٤٩
٣٢	فهرس المصادر والمراجع	٥١
٣٣	فهرس الأيات	٥٦
٣٤	فهرس الموضوعات	٥٧